

1500077-04.2022.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... que quem estava promovendo o tráfico ali era o acusado e o adolescente infrator T.N.O., ambos já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico. Durante a campanha, viram o réu e o adolescente realizando a venda de entorpecentes para duas pessoas que chegaram ao ponto de venda a pé, sendo que o adolescente realizava o atendimento aos usuários/compradores e o acusado se dirigia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500077-04.2022.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 23 de maio de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500077-04.2022.8.26.0344 - Controle 2022/000073

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES (RG: 55.253.477, filho de Ana Paula da Luz Fagundes), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 10h20min, na esquina das Ruas João Soares Rosa e Rua Maria Raspante, Bairro Jardim Edison da Silva Lima, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, ele e o adolescente T.N.O., agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vendiam, traziam consigo e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 15,46g (massa líquida) de cocaína e 119,36g (massa líquida) de Cannabis Sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 121/123), o réu foi citado (fls. 134) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/148).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações ministeriais às fls. 225/230 e alegações defensivas às fls. 233/253.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 23/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), fotografias (fls. 30/35), laudo de constatação (fls. 38/41), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 97/104) e pela prova oral colhida.

Na fase inquisitiva (fls. 6/7 e 8/9), os investigadores de polícia William Guilherme do Amaral e Renato José Garcia Madi declararam que foram colhidas informações a respeito de movimentação de tráfico de drogas na rua João Soares Rosa, esquina com a rua Maria Raspante, Jardim Edison da Silva Lima e, baseados em tais informações, realizaram campana em local estratégico. Disseram que conseguiram observar toda a movimentação do referido ponto de venda de drogas e constataram que quem estava promovendo o tráfico ali era o acusado e o adolescente infrator T.N.O., ambos já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico. Durante a campana, viram o réu e o adolescente realizando a venda de entorpecentes para duas pessoas que chegaram ao ponto de venda a pé, sendo que o adolescente realizava o atendimento aos usuários/compradores e o acusado se dirigia até um terreno baldio, distante aproximadamente trinta metros, pegava as porções de drogas, entregava aos usuários, recebia o dinheiro e repassava para o adolescente. Diante do flagrante delito, os policiais, com apoio de outra equipe, resolveram realizar a abordagem. Contaram que o adolescente, ao ver que seria abordado, jogou ao chão uma quantia de R\$5,00 (cinco reais) que estava em sua mão e, em sua revista pessoal, foi encontrado, no bolso da sua bermuda, o valor de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais) e duas porções de maconha, envoltas em invólucro plástico, além de um aparelho celular. Já em revista pessoal no acusado, encontraram uma porção de maconha, também envolta em invólucro plástico, igual àquela que estava com o adolescente. Em diligência pelo local dos fatos, foram até o terreno que estava sendo usado como esconderijo das drogas e, no meio do mato, embaixo de algumas telhas, encontraram um saco plástico contendo 47 (quarenta e sete) porções de maconha, 34 (trinta e quatro) microtubos de cocaína e 73 (setenta e três) microtubos de crack. Em juízo, os policiais ratificaram as declarações anteriores e ressaltaram que era clara a divisão de tarefas entre o acusado e o adolescente, sendo que o menor ficava com o dinheiro e o acusado buscava os entorpecentes no terreno baldio, próximo ao local dos fatos. Em solo policial (fls. 14/15), o acusado negou o crime de tráfico de drogas e afirmou ser apenas usuário de maconha e crack. Contou que estava ao local dos fatos para comprar maconha e já tinha comprado duas porções quando foi abordado pelos policiais. Afirmou conhecer o adolescente apenas de vista, nada sabendo a respeito do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Em seu interrogatório judicial, ratificou a versão dada na fase inquisitiva, afirmando ser apenas usuário e dizendo que estava no local apenas para comprar drogas e acabou preso com o adolescente, que estava vendendo. Disse que foi ameaçado pelos policiais e que eles até quebraram seu cachimbo. Ressaltou que, desde que foi preso, não usou mais drogas e voltou a trabalhar. Esclareceu que, no dia dos fatos, tinha acabado de chegar no local e reafirmou que era o adolescente que estava promovendo a venda de drogas naquele ponto. Salientou que já foi internado para tratamento de drogas quando era menor, pois usa entorpecentes desde criança, e, na época, estava usando crack. No dia dos fatos, contou que foi comprar maconha e crack, sendo que, quando foi abordado, já estava com a maconha e o menor buscava o "crack". Afirmou que conhece os policiais e nada tem contra eles. Por fim, salientou que traficante não deixa usuário vender drogas.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os investigadores são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não

há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus

nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos investigadores foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou condutas descritas nos artigos 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, expor à venda, ter em depósito e trazer consigo drogas, sem a devida autorização legal ou regulamentar. Vejamos.

Do exame dos autos, extrai-se que, após informações de ponto de venda de drogas, os policiais realizaram campana em local estratégico e flagranciaram o acusado em conjunto com um adolescente praticando o tráfico de drogas. Durante a observação velada, puderam ver toda a movimentação do referido ponto de venda de drogas e a divisão de tarefas dos envolvidos, pois presenciaram a venda de entorpecentes para dois usuários, sendo que o adolescente realizava o atendimento aos usuários/compradores e o acusado se dirigia até um terreno baldio, pegava as porções de drogas, entregava aos usuários, recebia o dinheiro e repassava para o adolescente. Desta forma, realizaram a abordagem e encontraram entorpecentes com os dois envolvidos e no terreno baldio, além de dinheiro proveniente do tráfico com o adolescente que atuava com o réu.

A corroborar o que foi dito pelos policiais há a própria declaração do réu afirmando que estava no local dos fatos com droga e com o menor infrator, o qual foi apontado, pelo acusado, como vendedor de entorpecentes. Assim, confirmou os depoimentos dos investigadores no sentido de que se encontrava em local conhecido pelo tráfico de drogas e estava com o adolescente. Ainda, o laudo de constatação (fls. 38/41) e o laudo definitivo de entorpecentes (fls. 97/104) dão conta que as substâncias encontradas com o adolescente, com o acusado e no terreno próximo ao local dos fatos, onde o réu fora visto, são entorpecentes.

Quanto à alegação de que seria mero usuário e não comercializaria drogas, restou refutada pela prova dos autos. Primeiro, porque os policiais, pessoas desinteressadas em condenações por crimes graves de quem sequer conhecem, afirmaram que o viram em conduta típica de comércio. Depois, o réu sequer comprovou o exercício de atividade lícita e disse que, na época, era usuário, a indicar que promovia a venda de drogas para sustentar seu vício. Da mesma forma, não trouxe nenhuma prova da condição de usuário, como, por exemplo, a testemunhal.

Sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela condição de traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (50 - cinquenta - porções de maconha, 34 - trinta e quatro - microtubos de cocaína e 73 - setenta e três - microtubos plásticos de crack e que atingiria inúmeros usuários - podendo o alto volume de drogas ser identificado visualmente pela fotografia de fls. 30), seu alto poder vulnerante, bem como as circunstâncias da prisão do réu (que se deu após visualização de ato típico de comércio de entorpecentes pelos policiais e em local de venda de drogas) revelam que se trata, o acusado, de traficante.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro; prisão em local já conhecido como ponto de venda de drogas; visualização, pelos investigadores, de atos de comércio), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP – Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Da mesma forma, não convence a narrativa apresentada pelo acusado de que os entorpecentes, exceto aqueles encontrados em suas vestes, não lhe pertenceriam, eis que não há razões para se duvidar do relato dos investigadores, pois não há qualquer indicação de inimizade que fariam com que eles incriminassem falsamente suspeito.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o acusado, ao que consta, se dedica à atividade criminosa, ou seja, o histórico de envolvimento do acusado com a criminalidade (processado quando menor por atos infracionais – fls. 47), bem como a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício.

Ainda, destaco que, conforme decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (cuja ementa se encontra colacionada a seguir), o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. 4. Hipótese em que o redutor não foi aplicado com base no fato de o paciente possuir diversos registros anteriores, como atos infracionais praticados quando menor, inclusive por tráfico de drogas, além de recente condenação criminal pela prática do mesmo delito, a denotar dedicação a atividades criminosas. 5. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 6. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021) No caso concreto, ainda, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista o envolvimento do inimputável T.N.O. (16 anos) no crime.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida, além do alto poder vulnerante de parte dela, autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que

demonstram o alto grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Pena final, portanto, em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios para fixação da pena privativa de liberdade, é imposta em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa imposta, por se tratar de crime equiparado a hediondo e também pelas circunstâncias levadas em consideração para o aumento da pena na primeira fase, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios no caso concreto.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar LEONARDO HENRIQUE FAGUNDES, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, tendo em vista a decisão emanada nos autos do HC n. 726.803/SP, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Não obstante, certifique, a z. Serventia, quanto ao cumprimento das medidas impostas. Em caso de descumprimento, vista às partes e conclusos.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e bens, apreendidos às fls. 28/29, oficiando-se à FUNAD.

Oportunamente, expeça o necessário para o cumprimento das penas impostas e desta sentença, na integralidade. Oficie-se ao TRE, para atendimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA